

1530192-02.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste prisma: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1530192-02.2021.8.26.0228 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 31 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1530192-02.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

TIAGO CAMPOS ROCHA DE ALMEIDA e outro

Vistos.

TIAGO CAMPOS ROCHA DE ALMEIDA e RAFAEL ROCHA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c. artigo 29, caput e artigo 61, I e II, "j", ambos do CP, porque, em 15 de dezembro de 2021, por volta das 15h30, na Viela Renaldo Laporta, altura do nº 04, Mandaqui, nesta Capital, em período de calamidade pública, traziam com eles, ocultaram, vendiam e expunham à venda, para fins de tráfico, 03 potes de cocaína em pó, com massa líquida total de 6,7 gramas, 28 porções de cocaína em pó, com massa líquida total de 18,4 gramas, 05 porções de cocaína em formato de "crack", com massa líquida total de 1,0 gramas, 17 porções de cocaína em pó, com massa líquida total de 9,6 gramas, 08 porções de tetrahydrocannabinol na forma da substância popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 1,2 gramas, 08 potes de tetrahydrocannabinol na forma da substância popularmente conhecida como "skunk", com massa líquida total de 3,5 gramas, e 29 porções de tetrahydrocannabinol na forma da substância popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 41,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida e a defesa preliminar foi apresentada.

Durante a instrução, foram juntados documentos, bem como foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados (audiovisual).

Memoriais (fls. 148/159 e 179/193).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de R\$40,00, 29 papélotes de maconha, 28 invólucros de cocaína, 5 papélotes de crack, 3 invólucros de cocaína, 8 invólucros contendo de maconha, 8 invólucros de maconha e 17 invólucros de cocaína (fls. 16); pelo auto de constatação das substâncias tetrahidrocannabinol e cocaína (fls. 21/23); e pelo laudo de exame químico-toxicológico, em que se atestou tratar de substâncias psicotrópicas de uso proscriuto no país (fls. 166/169).

Quanto à autoria é inconteste, diante da prisão em flagrante dos agentes, na posse do entorpecente apreendido em circunstâncias de mercancia, conforme testemunhos policiais.

Vejamos a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil Leonardo Vieira Bento disse que receberam denúncia e foram ao local apurar. Ficaram à distância de campana em viatura descaracterizada e viram pessoas se aproximando do Tiago, entregando dinheiro, e Rafael ia até um carro, pegava drogas na roda e entregava ao usuário. Eles não correram e foram abordados e nada foi encontrado com eles, exceto dinheiro com Tiago. Na roda do carro havia cocaína, maconha e crack, cerca de 60 porções. Ambos assumiram a traficância. A campana durou aproximadamente 20 minutos, a 50 ou 60m do réu. Eles estavam na rua, é uma viela estreita, o carro estava do outro lado da rua. Ora eles estavam juntos, ora separados, ora andavam pela rua. Há um ferro velho próximo dali e pessoas entravam e saíam. Na abordagem aproximou-se uma pessoa que estava de passagem. Era um Escort verde. As drogas ficavam na roda do carro. Rafael pegava a droga; Tiago era responsável pelo financeiro. Viram três ou quatro pessoas na campana e todas as vezes Tiago pegou o dinheiro e Rafael foi até o carro.

O policial civil Dionisio Gonzaga de Souza contou que começaram investigação por receber denúncias de tráfico no local. Foram até lá em viatura descaracterizada e passaram a observar. Viram algumas pessoas se aproximando de Tiago e entregando algo a ele, que depois souberam ser dinheiro. Após, ele ia até um veículo estacionado na via pública e retirava droga, entregando ao usuário. Isso ocorreu por três vezes na campana. Decidiram abordar e com o réu havia R\$40,00 e a droga estava em um nécessaire no carro. Tiago recebia valores e Rafael buscava as drogas no carro e entregava ao usuário. Rafael ficava envolta do carro e a droga estava na roda do veículo. Dois policiais participaram da ocorrência; ficaram 20 minutos, a cerca de 40 a 50m de distância. Na abordagem havia um terceiro indivíduo, com quem nada havia, que disse ser morador da região e ia à farmácia. Os dois estavam próximos, Tiago próximo de um muro e Rafael na rua se passando por morador de rua. Ali há um ferro velho com muitos moradores. Ele se trajava de morador de rua para passar despercebido. Eles não correram. Tiago negou ter pegado dinheiro de um dos usuários, o último antes da abordagem. Rafael alegou ser morador de rua. Com eles não havia drogas. Esse carro ficava a 10 a 15m de distância dos réus. Havia crack, cocaína e maconha.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática dos fatos descritos na denúncia pelos réus.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, até mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste credibilidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96 - p. 39.846).

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (STJ - HC 608.558 RJ 2020/0217527 - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 01.12.2020 - DJe 07.12.2020). Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

Pequenas contradições são inclusive salutares, pois demonstram a espontaneidade dos depoimentos. Nesse sentido:

Pequenas contradições nos depoimentos acusatórios não têm o condão de anular a prova oral, se estes são unânimes quanto ao principal. (TACRIM-SP - AP 1.085.033/8 - Rel. Oldemar Azevedo - j. 27.01.98 - RJTACRIM 37/335).

Sendo os depoimentos de várias testemunhas concordantes no essencial, mas divergentes em pontos secundários, não é mau, antes muito bom, que assim seja, porque revestem credibilidade, pois se fossem rigorosamente idênticos, ponto por ponto, passariam de imediato a impressão de que oriundos de uma única fonte, uma só matriz, artificialmente composta e fraudulentamente multiplicada. (TACRIM-SP - AP 1.030.635/3 - Rel. Corrêa de Moraes - j. 10.10.96 - RJTACRIM 33/83).

Não elide o conjunto probatório desfavorável pequenas e secundárias contradições que, ainda que existentes, não afastam os elementos essenciais comprovantes da atuação delituosa. (TACRIM-SP - AP - Rel. Chiaradia Netto - JUTACRIM-SP 20/285).

Com efeito, se versões desses policiais, onde eventual ocorrência de alguma omissão, contradição ou divergência é admissível e até normal, visto participarem de inúmeras diligências dessa natureza, no caso, seguramente alusivas sobre as notícias anônimas, a campanha realizada, a apreensão das drogas, além da condição do flagrante, a forma como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, sua quantidade e variedade, merecem credibilidade, pois nada há nos autos a sugerir que tivessem motivação lógica para falsamente o incriminarem. Outrossim, ressalvo que pequenas contradições nos depoimentos testemunhais são normais e não impressionam, é consequência natural da característica humana de diferentes maneiras de memorização e apreensão dos fatos, insuscetíveis de gerar insegurança a respeito do que efetivamente se passou. (TJSP - AP 0001330-86.2017.8.26.0535 - Rel. Paulo Rossi - j. 21.08.2019 - DJe 27.08.2019).

Ademais, os denunciados são confessos.

O réu Tiago Campos Rocha de Almeida relatou ter 23 anos, morar com o pai, trabalhar em metalúrgica, marmoreira, mas estar desempregado pela pandemia, ter estudado ensino médio completo, conhecer Rafael no dia. Admite os fatos. No dia estava ali pela primeira vez. Rafael já tinha ido comprar duas ou três vezes, faltando alguns reais. Pediu uma força em troca de papalotes de crack.

O réu Rafael Rocha da Silva contou ter 33 anos, morar com a esposa, em um barraco, trabalhar com reciclagem em um ferro velho, ter estudado ensino médio incompleto, conhecer Tiago no dia da prisão. Admite os fatos. Não tinha dinheiro para drogas e então foi ajudar Tiago para ele lhe dar a droga. Está arrependido.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP e no

artigo 42 da Lei de Drogas, fixa-se a pena base no mínimo legal para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em relação à atenuante da confissão de Tiago, não se admite que a pena seja diminuída para aquém do mínimo. Nesse sentido, a Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Nesse mesmo sentido: Menoridade. Circunstância atenuante que, todavia, não pode implicar redução da pena fixada no mínimo legal (STF – HC – Rel. Sidney Sanches – RTJ 118/928). Ainda: (RT 737/551, 735/535, 735/568). Quanto a Rafael devem ser levadas em conta a agravante da reincidência (furto) e a atenuante da confissão, compensando-as. Determina o artigo 67 do CP que, “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. Pois bem, depreende-se que a reincidência, de fato, tem caráter preponderante sobre quase todas as demais causas de aumento e diminuição desta segunda fase, salvo sobre aquelas que também se refiram à personalidade do agente. Assim, se a reincidência revela traço da personalidade do acusado, tendente a permanecer no mundo do crime, o fato é que a confissão também o faz; ainda que tardia, demonstra que o acusado procurou colaborar com a Justiça, sem apresentar subterfúgios que atrapalhassem a apuração da verdade real. A este respeito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE SE MOSTRA DEVIDA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Incide a atenuante da confissão espontânea, quando o réu admite a prática do fato a ele imputado e suas declarações são sopesadas para corroborar o acervo-fático probatório e fundamentar a sua condenação, ainda que invoque alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea (HC n. 365.963/SP, de relatoria do Min. Felix Fischer). 3. Ordem concedida, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do paciente, compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, por conseguinte, tornar a sua pena definitivamente em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. (STJ – HC 514032 RJ 2019/016769-8 – Rel. Rogerio Schietti Cruz – j. 25.06.2019 – DJe 01.07.2019).

Consigne-se, quanto à agravante contida no artigo 61, II, j, do CP, que não há relação de causalidade entre o momento vivenciado no período de calamidade pública e a prática do tráfico de drogas: não se vislumbra que a pandemia pelo Coronavírus tenha sido a causa ou a facilitadora do referido delito. A exasperação da pena somente é devida quando o agente se aproveita desta situação para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie. Citam-se jurisprudências: Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de ecstasy, lança perfume, crack, cocaína e maconha – Insurgência do réu – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5, pelo fato de o réu estar em liberdade provisória e, ainda, em razão da quantidade e natureza das drogas – Respeitado o entendimento do nobre julgador, o fato de o réu estar em liberdade provisória não justifica a exasperação da pena-base, de conformidade com o teor da Súmula 444, STJ – Pena-base que fica aqui estabelecida na fração de 1/6 em virtude da natureza-quantidade de entorpecentes apreendidos – Segunda fase – Presença das agravantes de reincidência e calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/4 – Agravante contida no art. 61, II, alínea “j”, CP, que não tem aplicação no caso – Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas – A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que

não ocorre na espécie – Agravante afastada – Pleito para o reconhecimento da atenuante inominada – Não cabimento – População mundial afetada pelo Covid19 e não apenas os grupos mais vulneráveis – Não foi o contexto gerado pela pandemia que levou o acusado a delinquir, tendo em vista que ele é reincidente por delitos ocorridos antes do Covid19 atingir o país – Majoração da pena na segunda fase em virtude da dupla reincidência, na fração de 1/5 – Redutor contido do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas – Não cabimento “Bis in idem” – Inexistência – Réu reincidente – Regime fechado – Detração penal – Impossibilidade Dicção do art. 387, § 2º, do CPP Prequestionamento Inexistência de violação à lei federal ou dispositivo constitucional Recurso provido em parte apenas para redimensionar o quantum da reprimenda. (TJSP – AP 1512902-08.2020.8.26.0228 – Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto – j. 13.10.2020 – DJe 13.10.2020).

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de provas sobre a dedicação do réu Tiago a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo-se a pena em 2/3, totalizando-se 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. E não se reconhece a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, em relação a Rafael, em virtude da reincidência por furto.

Observa-se que o fato de se considerar a agravante na segunda etapa da dosimetria não impede que seja sopesada para analisar questão relativa ao cabimento da minorante, mormente porque a circunstância reflete ou repercute em momentos e para fins distintos, por força de dispositivos legais claros (artigo 68 do CP e artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06): Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus. 2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem. 4. Recurso não provido. (STF – RHC 121598/SP – Rel. Ministro Dias Toffoli – j. 21.10.2014). Não resta caracterizado 'bis in idem' na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes. (STF – HC 205.295/SP). Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. (STF – RE com Agravo 929.416/SC – Rel. Marco Aurélio – j. 18.11.2015). Recentíssimos julgados do Superior Tribunal de Justiça não dissentem, consignando-se que: Não resta caracterizado 'bis in idem' na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art.33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas Corpus denegado (STJ – HC 148.575/SP).

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica dos réus. Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “c” e § 3º, do CP, fixa-se o regime aberto de cumprimento de pena para Tiago; para Rafael, pela reincidência, o regime é o semiaberto, conforme letra “b” do mesmo dispositivo. Não há que se olvidar que o tema 600 do Recurso Repetitivo do STJ dispõe: O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. O regime intermediário é fixado pra Rafael, pois o delito foi praticado sem a violência ou grave ameaça, sendo que é usuário de drogas e comercializou para sustento de seu vício. Permaneceu inalterada a situação fática que determinou a decretação da prisão cautelar anteriormente de Rafael, presentes, ainda, os requisitos legais,

não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o denunciado, ordenar sua liberação, sem prejuízo do conhecimento de eventual recurso de apelação. Consoante o artigo 387, § 2º, do CPP, mantém-se o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o artigo 112 da LEP. Neste prisma: TJSP – AP 0045877-82.2014.8.26.0224 – Rel. Luiz Antonio Cardoso; e TJSP – AP 0004038-54.2014.8.26.0361 – Rel. Luiz Augusto de Sampaio Arruda. Em relação a Tiago, solto, assim permanece.

Diante do exposto, CONDENO o réu TIAGO CAMPOS ROCHA DE ALMEIDA às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/06; e CONDENO o réu RAFAEL ROCHA DA SILVA às penas de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em relação a Tiago, presentes os requisitos do artigo 44, caput, do CP e verificando-se que as medidas são socialmente recomendáveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, nos termos do artigo 46 do mesmo diploma, em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Criminais, descontado eventual período de custódia cautelar, e prestação pecuniária à entidade social no valor de um salário mínimo, que pode ser dividido. Nomeia-se a FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 8946-X. Quanto ao corréu Rafael reincidente, impedida está qualquer benesse.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste prisma: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. PENA. REGIME. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I – Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, o Plenário desta Corte, ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico, por ser incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. II – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III – Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de piso que: i) superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para a fixação do regime aberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada, e ii) afastado o óbice à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, analise se o paciente preenche os requisitos para a referida substituição. (HC 114029-SP – Rel. Ricardo Lewandowski – j. 18.02.2012 – DJe 22.02.2013).

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ – HC184497-SP – Rel. Jorge Mussi – j. 07.02.2013 – DJe 19.02.2013 e HC 216197-RS – Rel. Laurita Vaz – j. 07.02.2013 – DJe 18.02.2013. Também nesse sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva de habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quanto o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Como é cediço, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexistente a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do CP. 3. Quanto à possibilidade de substituição da pena, nos delitos de tráfico, o Supremo Tribunal Federal, em 1/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritiva de direitos. 4. No caso, tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, bem como considerada a quantidade não expressiva de droga apreendida, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§2º e 3º, do CP, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 5. Habeas corpus não reconhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. (STJ – HC 463246 SP 2018/0200421-1 – Rel. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 18.10.2018 – DJe 26.10.2018).

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, expeça(m) ou adite(m)-se a(s) guia(s) de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; façam-se as comunicações; atualize-se o histórico de partes; archive-se; expeça(m)-se mandado(s) de prisão, se for o caso; uma vez cumprido(s), expeça(m)-se guia(s) de recolhimento, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente; caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), aguarde-se em escaninho próprio, cobrando-se a cada 120 dias; ou designe-se audiência para regime aberto; deverá(ão) o(s) réu(s) ser intimado(s) no último endereço onde foi(ram) encontrado(s); caso o(s) réu(s) não seja(m) encontrado(s), expeça(m)-se mandado(s) de prisão, fazendo constar que o(s) réu(s) deverá(ão) ser imediatamente apresentado(s) a este Juízo para participar da audiência de regime aberto e, após, será(ão) posto(s) imediatamente em liberdade; decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o(a) proprietário(a) do(s) bem(s) apreendido(s) manifeste interesse na restituição, expeça-se ofício ao setor de armas e objetos, autorizando o leilão ou destruição, nos termos do artigo 123 ou 124 do Código de Processo Penal; o dinheiro deverá ser revertido em favor do FUNAD; se for o caso, requirite-se da autoridade policial a remessa da guia de depósito do valor apreendido, com prazo de 30 dias; findo, reitere-se, sob pena de crime de desobediência, oficiando-se à Corregedoria da Polícia Civil; oficie-se para destruição das drogas; fica(m) desde já o(s) réu(s) intimado(s) a pagar os dias-multa, em 10 dias a contar do trânsito em julgado, com consectários legais (Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta 139.521-1, Titular Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo); na hipótese de quitação, abra-se vista ao Ministério Público e, após, venham conclusos para declaração da extinção da punibilidade da pena de multa; caso não seja efetuado o pagamento da multa, encaminhe-se à Vara das Execuções Criminais competente para cobrança, na forma da Lei n. 13.964/2019.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
Juiz(a) de Direito